

1500035-28.2022.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... de envolvimento de ambos com o tráfico (algo que se extrai da pretérita deflagração de investigação e diligências capazes de confirma-la), somam-se o recebimento de denúncias anônima minunciosa (que fazia menção expressa ao tráfico, às pessoas responsáveis pela droga e ao local onde se fazia a divisão e embalo que antecede a venda), a variedade de substância entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500035-28.2022.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500035-28.2022.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2002986/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 22269935 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 17/22/316 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2002986 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2002986/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUE HENRIQUE DELFINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

JHONATAN HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA e KAUÊ HENRIQUE DELFINO, já qualificados nos autos da ação penal em epígrafe, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 16:00 horas, na Rua 16 de Julho, nº 104, bairro Santa Luzia, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, tinham em depósito, para fins de tráfico e nas imediações de entidades de ensino, sociais, culturais, recreativas e esportivas, 323 (trezentas e vinte e três) porções de maconha que pesavam aproximadamente 1kg e 01 (uma) porção de cocaína na forma de crack que pesava aproximadamente 100g, substâncias entorpecentes que causam dependência

física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, Policiais Civis locais receberam denúncia anônima que não apenas atribuía aos acusados a embalagem de drogas, mas também indicava o local onde se dava aquela atividade espúria. Tais agentes públicos se dirigiram ao endereço mencionado naquele informe apócrifo e, quando da observação velada feita para aferir a verossimilhança do relato, identificaram movimentação suspeita (ambos entravam e saíam do imóvel a todo tempo). Deliberaram, então, ingressar na residência e surpreenderam ambos no exato instante em que de fato embalavam fartas porções de maconha e crack. Além da droga já mencionada, apreenderam-se no local balança de precisão, caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico e dinheiro (R\$ 246,00 em notas diversas).

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/166 e vem instruído com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar, e com o relatório da Autoridade Policial.

Os acusados foram então regularmente notificados e apresentaram resposta escrita, na forma do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 182, 213/214, 224, 229, 235, 236/238 e 239). Recebida a denúncia (e aditamento feito para incluir a causa de aumento de pena inscrita no artigo 40, VI, da Lei de Tóxicos), seguiram-se as citações (fls. 258/260, 293 e 297).

Na audiência atermada a fls. 301/302 interrogaram-se os réus e ouviram-se 04 (quatro) testemunhas. Na mesma oportunidade converteu-se o julgamento em diligência para cobrar relatório (de investigações) mencionado por uma das testemunhas, vindo tal documento encartado a fls. 316/321.

Em alegações finais, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 333/345). O I. Defensor constituído pelo corréu JHONATAN postulou a fixação da pena em seu patamar mínimo, a compensação das circunstâncias agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), o afastamento da causa de aumento de pena inscrita no artigo 40, III, da Lei de Tóxicos, a adoção de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade (fls. 350/369). O I. Defensor constituído pelo corréu KAUÊ, por fim, postulou a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu grau mínimo, o afastamento da causa de aumento de pena inscrita no artigo 40, III, da Lei de Tóxicos, a aplicação da causa de diminuição da pena inscrita no artigo 33, § 4º, do referido diploma legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e adoção de regime inicial diverso do fechado (fls. 377/385).

Relatados, D E C I D O.

Tratam estes autos de tráfico de entorpecentes perpetrado nas imediações de entidades de ensino, sociais, culturais, recreativas e esportivas, delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A pretensão punitiva posta na denúncia é mesmo procedente.

Enquanto a materialidade descende da prova consubstanciada no auto de exibição e apreensão e nos laudos periciais encartados a fls. 15, 16/17, 193/200, 201/203, 204/206 e 207/211, a autoria restou suficientemente demonstrada em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas de forma segura e coesa, sem dúvidas ou contradições capazes de recomendar algum descrédito, além da confissão (parcial) dada pelo corréu JHONATAN.

Como se infere do incluso auto de prisão em flagrante, Policiais Civis locais

receberam denúncia anônima que não apenas atribuía aos acusados a embalagem de drogas, mas também indicava o local onde se dava aquela atividade espúria. Tais agentes públicos se dirigiram ao endereço mencionado naquele informe apócrifo e, quando da observação velada feita para aferir a verossimilhança do relato, identificaram movimentação suspeita (ambos entravam e saíam do imóvel a todo tempo). Deliberaram, então, ingressar na residência e surpreenderam ambos no exato instante em que de fato embalavam fartas porções de maconha e crack. Além da droga já mencionada, apreenderam-se no local balança de precisão, caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico e dinheiro (R\$ 246,00 em notas diversas).

Dir-se-á não ter validade a referida prova, porquanto produzida na fase inquisitorial, onde não se atenta para os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não se deslembre, entretanto, da sua renovação em Juízo, advindo daí inquestionável credibilidade.

Quando ouvidos durante a instrução criminal, os Policiais Civis Mário Henrique Fernandes Silveira e Matheus Oliveira de Souza ratificaram, em sua inteireza, os relatos antes dado ao Delegado de Polícia que presidiu a lavratura do auto de prisão em flagrante; reafirmaram não apenas a revelha suspeita de envolvimento de ambos com o tráfico de drogas, mas também as investigações anteriores (que conferiam verossimilhança àquela suspeita), além do recebimento de denúncia anônima que atribuía a ambos os réus a embalagem de droga num determinado imóvel, motivo da ação deflagrada naquela data; foram além disso, aliás, para referir ainda a realização de nova campana antes da incursão no imóvel e, sobretudo, a detenção de ambos no exato momento em que de fato dividiam e embalavam droga em porções propícias ao comércio; registraram, por fim, a apreensão também de balança de precisão, tesoura, caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico e dinheiro.

E a despeito do entendimento comumente esposado em casos deste jaez, não há como inquirir a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, mormente quando ausente qualquer fato concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito. É que a simples condição de Policial não autoriza conclusão sobre parcialidade ou falta de isenção capaz de infirmar os respectivos relatos, quiçá sobre a sugerida predisposição de imputar crimes a inocentes. Trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0 – SP).

Confirmam-se ainda, porque pertinentes, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPPE, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais

envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PROVA CRIMINAL - Depoimento de Policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. Segurança nas versões apresentadas - Recurso provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (Apelação Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95).

PROVA CRIMINAL - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida. O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a Juízo para perseguir pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes (Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - Relator: Djalma Lofrano - 18.08.94).

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre presunção juris tantum de legitimidade de sua atuação (Apelação Criminal n. 172.521 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95).

Aliás, "seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito" (Apelação n. 1.002.771/3, SP, 11a Câmara - Relator: Xavier de Aquino).

E aqui, repita-se, denúncias anônimas anteriores atribuíam a ambos os acusados posição de destaque no tráfico de drogas local ("gerência"), advindo daí investigação que outorgou verossimilhança à suspeita (observações veladas constatarem que ambos entravam e saíam do imóvel de forma pouco usual e rigorosamente compatível com a atividade ilícita que se imaginava). Na data dos fatos tais agentes públicos recebem nova denúncia anônima que referia a embalagem naquele exato momento e, mercê da fundada suspeita, deliberam conferir a veracidade do informe. Tão logo ingressam na residência (localizada em notório ponto de tráfico de drogas da Comarca, aliás), surpreendem ambos os réus no exato momento em que, de fato, dividiam a droga. Apreendem no local, outrossim, não apenas fartas porções de maconha já divididas e embaladas em porções individuais (sachês) adequadas ao comércio e relevante porção de crack ainda por repartir, mas também tesoura, balança, dinheiro e caderno com anotações deveras compatíveis com aquelas da contabilidade do tráfico de drogas...

Ora, tangencia a mais cândida ingenuidade ignorar tão íntima relação entre os fatos e acreditar, sinceramente, estar-se diante de mera e singela coincidência, ou de "invenção" de Policiais Civis que não apenas urdiram trama tão sórdida quanto bem concatenada, mas também providenciaram relevantes porções de maconha e crack, balança de precisão e caderno com anotações e empregaram valores de seus soldos tudo para forjar a prisão e incriminar pessoas inocentes, probas e trabalhadora!

Há mais, porém.

Quando do interrogatório judicial, o corréu JHONATAN nem sequer negou a posse de tantas e quantas porções de droga e a finalidade diversa do consumo pessoal (disse guardá-la mediante paga ou promessa de pagamento para um traficante cujo nome não quis revelar).

Nessa parte, contudo, a negativa restou não apenas isolada, mas também inverossímil.

A uma, pois a ação policial não foi obra do acaso; ao revés, sucedeu o recebimento de denúncias anônimas deveras minuciosas e a realização de diligências (campanas) que outorgaram viabilidade àquela suspeita. E afastada a remota hipótese de os agentes públicos adivinharem a existência de droga no local, é porque de fato receberam tais informes, cuja riqueza de detalhes toram pouco crível partir de alguém que não conhecesse, de fato, aquele esquema assaz ilícito.

A duas, pois ali não havia apenas droga, senão também tesoura, balança de precisão e embalagens plásticas, além de caderno utilizado para a contabilidade do tráfico. Confirmam-se, a propósito, não apenas o laudo pericial encartado a fls. 193/200, mas também o relatório trazido a fls. 316/321 (donde constam fotografias deveras eloquentes, aliás). E que não nos percamos em idiossincrasias, mas avilta o mais comezinho imaginar que o singelo “depositário” da droga também a embale e, mais que isso, se encarregue da escrituração de todos os dados inerentes àquele comércio espúrio, como quis fazer crer o corréu JHONATAN.

A três, pois se as denúncias anônimas se mostraram verdadeiras em relação ao local onde a droga era armazenada e à identificação da pessoa encarregada de tal mister, difícil entrever justo motivo para desacreditá-la na parte em que identifica o efetivo e concreto distribuidor do entorpecente...

A quatro, pois a justificativa apresentada por tal acusado para a guarda droga (carência financeira), sobre não comprovada, nem tem sentido lógico algum: se já dispunha ele de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) no local, por que motivo se arriscaria em guardar tantas e quantas porções de droga para receber quantia semelhante (R\$ 300,00)???

O corréu KAUÊ, por sua vez, se limitou a negar qualquer relação com a droga apreendida em poder do amigo e asseverar que sua presença no local se deve ao acaso.

Nada mais despropositado.

Como já registrado alhures, a denúncia anônima foi certa em apontar não apenas quem guardava droga (JHONATAN), mas também o local onde havia droga (casa de JHONATAN) e até mesmo o horário em que ambos estariam a dividi-la e embalá-la. Por que motivo, então, não se há de acreditar naquele informe na parte em que diz que tal atividade espúria era perpetrada também pelo corréu KAUÊ???

E não é só.

Não bastasse o fato de os Policiais Civis lotados no Setor de Investigações da Delegacia de Polícia local afirmarem com todas as letras a preexistência de revelha suspeita de envolvimento de ambos com o tráfico de drogas, curial notar que as campanas feitas cuidaram de confirmar a presença constante do corréu KAUÊ no imóvel onde as fartas porções de drogas foram encontradas.

Não se deslembre, outrossim, de que tal corréu nem sequer logrou justificar, de forma convincente, a razão pela qual, curiosa e coincidentemente, se dirigiu à casa do corréu JHONATAN na hora exata que a droga era dividida e embalada...

Memento: a mais singela e despreocupada leitura dos depoimentos prestados pelos Policiais Civis autoriza inferir, indene de dúvidas, que a droga e demais petrechos utilizados na divisão e no embalo não estavam guardados dentro de um armário, senão exposto sobre a mesa. E à vista da inexistência de qualquer fato concreto – mínimo que fosse – capaz de incutir alguma dúvida sobre a veracidade dos relatos dados pelos agentes públicos, ninguém em sã consciência e perfeito juízo se abalará a conferir maior valor à versão de criminosos em detrimento daquelas emanadas de quem foi legítima e regularmente credenciado pelo Estado.

Aquelas questiúnculas sobre haver droga também num armário nem tem a relevância que se lhe empresta a Defesa. Nada obsta – nada mesmo – estivesse parte dela sobre a mesa (para divisão e embalo) e parte no armário, sem que disso se extraia dúvida relevante capaz de tornar suspeitos os Policiais Civis e frágil a prova...

Nem se faz necessária maior digressão, outrossim, para afastar a subsunção da conduta dos acusados à regra do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

À preexistência de fundada suspeita de envolvimento de ambos com o tráfico (algo que se extrai da pretérita deflagração de investigação e diligências capazes de confirmá-la), somam-se o recebimento de denúncias anônima minuciosa (que fazia menção expressa ao tráfico, às pessoas responsáveis pela droga e ao local onde se fazia a divisão e embalo que antecede a venda), a variedade de substância entorpecente (maconha e crack), a quantidade (nada menos que 323 porções de maconha que pesavam aproximadamente 1kg e 01 porção de crack que pesava aproximadamente 100g), a existência de petrechos deveras úteis àqueles que se dedicam ao comércio de tais substâncias (tesoura e caderno com anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico), a existência de dinheiro (não apenas sem origem lícita comprovada, mas também em quantidade igualmente compatível com aquela atividade espúria anunciada) e, finalmente, a confissão do corréu JHONATAN (no sentido de que a droga não se destinava ao seu próprio consumo)....

Quando do julgamento da apelação criminal nº 990.09.208391-0 desta Comarca de Mogi Mirim, aliás, a C. 1ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator o eminente Desembargador Figueiredo Gonçalves, assentou ser sintomático também que em poder dos apelantes, fosse encontrada uma balança de precisão. Não a teriam com eles para conferir peso de eventuais entorpecentes adquiridos para mero consumo pessoal. Afinal, usuários adquirem unidades já pesadas pelo vendedor e não discutem nessa ocasião. Contudo, se vendedor da droga, tem o interesse em saber quanta possui e como dividi-la para os lucros do negócio, necessitando daquele instrumento de precisão para embalar as unidades ou conferir o que adquire por grosso...

Conquanto inexistentes atos com idoneidade para indicar a concreta venda de droga na data indicada na denúncia, cumpre rememorar que a incidência do artigo 33 do sobredito diploma legal prescinde da efetiva negociação. Ali, ao revés, são previstas inúmeras outras condutas, como aquela posta com clareza solar na denúncia (ter em depósito). Trago à colação o seguinte julgado:

Traficante não é apenas aquele que comercia entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que as tem em depósito (TJRS – AC – 69.100.048-3 – Rel. Nilo Wolff – RJTJRS 151/216). Destaquei.

Embora possível, os acusados não comprovaram a origem lícita dos valores encontrados. Daí concluir-se tratar-se mesmo de proveito auferido com o tráfico de entorpecentes e, por isso mesmo, a pertinência do perdimento, inclusive do veículo automotor utilizado reiteradamente para a prática do crime.

Para VICENTE GRECO FILHO, outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do

ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá o acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes. Algo intuitivo, aliás, porque a ressabida inexistência de registros formais acerca da origem de numerário e bens em casos deste jaez torna absolutamente impossível carrear à acusação a prova de tal ilicitude.

Confira-se ainda, porque relevante, o ensinamento de PAULO JOSÉ DA COSTA JR., para quem a lei penal previu o confisco dos instrumenta sceleris (art. 91, I) e dos producta sceleris (n. II, b)... Instrumentos do rime são os utensílios que se prestam ao seu cometimento. Confisco é a perda de vens do particular em favor do Estado. Nem todos os instrumentos poderão ser confiscados, mas somente aqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção configurem um ilícito... Produtos do crime são as coisas obtidas diretamente com a infração (res furtiva), mediante operação subsequente (jóia fabricada com o ouro furtado), criadas pelo crime (moeda falsa), ou adquiridas com a alienação dos objetos furtados. Apreendidos os instrumentos e o produto do crime, serão destruídos (CPP, art. 124), leiloados (CPP, arts. 122 e 123), ou recolhidos a museu (CPP, art 124)... Os instrumentos apreendidos pela autoridade policial, desde que relacionados com o crime, não poderão ser restituídos a seus titulares enquanto interessarem ao processo e durante toda a sua tramitação (CPP, arts. 6º e 118). A apreensão antecede o confisco. É pressuposto deste. Destaquei.

JHONATAN HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA e KAUÊ HENRIQUE DELFINO, então, praticaram fato antijurídico, subsumível em tipo penal e, ante as suas culpabilidades, impõe-se-lhes as respectivas sanções penais que passo a dosar.

I - Do corrêu JHONATAN:

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre notar a inexistência de relevantes antecedentes criminais (tirante aquela condenação proferida nos autos da ação penal nº 0004585-20.2016.8.26.0363 cujo trâmite se deu perante a 4ª Vara local e há de ser considerada na próxima fase da dosimetria da pena). Não há se olvidar, contudo, a expressiva quantidade de droga apreendida (nada menos que 323 porções de maconha que pesavam aproximadamente 1kg e 01 porção de crack que pesava aproximadamente 100g). Debuxa-se daí não apenas maior lesão ao interesse jurídico tutelado pela norma, mas também, e principalmente, maior culpabilidade e maior reprovabilidade da conduta. Ora, são sabidos, plenamente sabidos, os malefícios advindos de tais substâncias, assim como a estreita relação existente entre o comércio de drogas e os mais variados e graves crimes. Justifica-se, pois, o arbitramento de pena acima no mínimo legal, compatíveis com tais circunstâncias, sob pena de se dispensar a ele tratamento idêntico àquele merecido por pessoas que possuem, transportam ou trazem consigo, para o consumo de terceiros, quantias bem menos significativas. Reporto-me, uma vez mais, à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

A quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria (STJ - HC - 10.165 - Rel. Félix Fischer - j. 9.11.1999 - DJU 14.2.2000, p. 53).

Ao proceder a individualização da pena, o Juiz após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social, e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e consequências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento de pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente abrandada, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade (STJ - 6a Turma - REsp. 90.171 - Rel. Luiz Vicente Cernichiaro - j. 08.10.1997 - DJU 12.08.1997, p. 36.287).

Para a exarcebação é permitido ao juiz, diante das circunstâncias judiciais, apreciar o alto grau de reprovabilidade da conduta (STJ – 5ª Turma – Rel. José Arnaldo da Fonseca – REsp. 195.222 – j. 02.09.1999 – DJU 11.10.1999, p. 83, e RT 773/552).

Com tais premissas, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O documento encartado a fls. 177/178 indica mesmo a reincidência, circunstância agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal. Daí acrescimo, à razão de 1/6, para perfazer 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Conquanto presente a confissão espontânea (parcial, aliás, na exata medida em que refutou a dinâmica descrita pelos Policiais Cíveis e negou participação do segundo acusado), não é caso de se fazer redução sob tal rubrica, ante a prevalência das circunstâncias pessoais referidas no artigo 67 do Código Penal:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105543, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014). Destaquei.

CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário (RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Destaquei.

Com relação às causas de aumento de pena, dá-se que tráfico foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (Escola Estadual Professor Ernani Calbucci) e de entidades recreativas/esportivas (Estádio Municipal Ângelo Rotolli e Ginásio Poliesportivo Wilson Fernandes Barros) consoante laudo encartado a fls. 207/211, advindo daí perfeita subsunção do fato àquela norma inserta no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Daí derradeiro acrescimo, à razão de 1/6 (um sexto), para perfazer 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Não há causas gerais ou especiais de diminuição de pena (não bastasse o fato de a revelha suspeita de envolvimento com o tráfico e a quantidade de droga tornarem pouco crível tratar-se de sua primeira incursão no crime, a reincidência afasta, em absoluto, a aplicação da norma inserta no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Torno definitiva a pena privativa de liberdade deste primeiro acusado, dessarte, em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 907 (novecentos e sete) dias multa, previsão legal mínima para o delito modificada, na mesma proporção, pelos acrescimos advindo das circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e variedade de drogas), pela agravante (reincidência) e pela causa especial de aumento de pena (crime perpetrado nas imediações das entidades referidas no artigo 40, III, da Lei de Tóxicos). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a

presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira do réu.

II - Do corrêu KAUÊ:

Valendo-me do quanto exposto em relação ao primeiro acusado (quantidade relevante de droga), fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Com relação às causas de aumento de pena, dá-se que tráfico foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (Escola Estadual Professor Ernani Calbucci) e de entidades recreativas/esportivas (Estádio Municipal Ângelo Rotolli e Ginásio Poliesportivo Wilson Fernandes Barros) consoante laudo encartado a fls. 207/211, advindo daí perfeita subsunção do fato àquela norma inserta no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Daí derradeiro acréscimo, à razão de 1/6 (um sexto), para perfazer 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há, por fim, causas de diminuição de pena, pois a despeito da primariedade, reiterada jurisprudência tem afastado a incidência do redutor previsto no § 4º naqueles casos em que as circunstâncias do delito evidenciam que o acusado se dedicava a atividades criminosas. Quando do julgamento do AgRg no AREsp 628.686/MG, assentou a Colenda 6ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relatora a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais”. Destaquei.

No mesmo sentido o v. aresto proferido nos autos do HC 484.129/SP, relator o eminente Ministro Felix Fischer, para quem não se pode desprezar que “(...) na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes” (STJ, HC 484.129/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Destaquei.

Confira-se ainda, porque relevante, trecho do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

(...) Ademais, em razão da diversidade, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, deixo de aplicar a causa especial de redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Com efeito, foram apreendidos 248,66 gramas de maconha e 4,68 gramas de cocaína na forma de crack (fls. 152/156, 235/239, 241/ 245 e 250/254). Deveras, não somente a natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos indicam a impossibilidade da concessão do benefício, mas também a sua quantidade, forma de acondicionamento e peso líquido e as circunstâncias que cercaram a apreensão do entorpecente, após denúncia anônima. Tais elementos de prova demonstram que não se trata de traficância inédita, que pudesse qualificar o apelante como “traficante de primeira viagem” ou “pequeno traficante” (aquele que comercializa drogas apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), mesmo porque não se obtém tal monta, variedade e tipo de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia tal quantidade de droga a alguém que não tenha alcançado o mínimo de confiabilidade dentro da cadeia do tráfico (...) (Apelação Criminal nº 0012097-81.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí - 15ª Câmara de Direito Crimina - Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti - 13/06/2019). Destaquei.

E aqui, repita-se, não bastassem a preexistência de fundada suspeita de tal acusado com o tráfico de drogas (inclusive em posição de destaque) que justificou e deu razão de ser à realização de diligências policiais, na data do fato tais agentes públicos tornaram a receber denúncia anônima que não apenas confirmou aquela suspeita, mas também, e principalmente, bem demonstrou que o envolvimento dos acusados com o tráfico se perpetuava no tempo.

Não bastasse isso, a quantidade e variedade de droga (nada menos que 323 porções de maconha que pesavam aproximadamente 1kg e 01 porção de crack que pesava aproximadamente 100g), bem como os petrechos apreendidos (balança de precisão e caderneta com anotações da contabilidade) demonstram, às escâncaras, que não se tratava de fato único ou inédito, senão bastante recorrente...

Difícil, senão impossível, então, imaginar tratar-se de sua primeira incursão na mercancia ilícita e, por isso mesmo, ignorar sua dedicação a atividade criminosa, motivo bastante para afastar a aplicação do redutor...

Torno definitiva a pena privativa de liberdade, dessarte, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa, previsão legal mínima para o delito modificada, na mesma proporção, pelo acréscimo proporcionado pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e variedade de drogas) e pela causa de aumento de pena (crime perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino e entidades recreativa/esportiva). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira do réu.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO: I) JHONATAN HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA, já qualificado nos autos, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como no pagamento de 907 (novecentos e sete) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 e 61, I, do Código Penal e; II) KAUÊ HENRIQUE DELFINO, também qualificado, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como no pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Sem prejuízo e, com fundamento nos artigos 60 e 63 do primeiro diploma legal acima referido DECRETO o perdimento em favor da União (SENAD) dos valores apreendidos com os acusados.

Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). O crime por eles perpetrado é deveras grave e, por isso mesmo, nem guarda compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº

0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Salles Abreu - 04/10/2011).

E ainda:

PENA - Restritivas de direitos - Tráfico de entorpecentes - Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) - Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 17/08/2006 - V.U.).

PENA - Restritivas de direitos - Réu condenado por tráfico de entorpecentes - Substituição da reprimenda privativa de liberdade - Inadmissibilidade - Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 27/09/2006 - V.U.).

O corréu JHONATAN, como já registrado alhures, é reincidente.

Não têm os acusados, outrossim, direito à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

O regime inicial do cumprimento das penas impostas há de ser o fechado, único compatível com a gravidade do crime, suas peculiaridades (quantidade relevante de droga e possível - senão provável - posição de destaque, retius, "gerência", no tráfico da região), com a quantidade da sanção e, em relação ao corréu JHONATAN, com a reincidência.

Presentes em relação ao corréu JHONATAN os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade (HC nº 867.918-3/3 - Araraquara - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Sérgio Rui - 06/10/2005 - V.U.; HC nº 517.60/0-00 - São Paulo - 13ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lopes da Silva - 09/06/2005 - V.U.). À gravidade objetiva do crime (daqueles equiparados aos hediondos e que, por isso mesmo, evidenciam periculosidade do agente) e suas peculiaridades (quantidade expressiva de droga e petrechos indicativos da reiteração criminosa), soma-se a reincidência. E se a despeito de inquérito, processo, condenação e prisão anteriores insiste em delinquir, demonstra personalidade voltada para o crime, indiferença para com a lei penal, além da absoluta ineficácia dissuasória da sanção imposta na ação penal pretérita. Daí a estrita necessidade da custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública e a própria credibilidade da Justiça. Recomende-se, pois, tal acusado na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a expedição de novo mandado de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele pleitear eventual progressão de regime na execução provisória, se e quando atendido, os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Com relação ao corréu KAUÊ e, mercê da concessão de Habeas Corpus pela E. Superior Instância (registro nº 2003312-81.2022.8.26.0000), nada parece justificar a alteração do status quo. Faculto em relação a ele, então, o apelo em liberdade.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e à SENAD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes. Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão em desfavor do corréu KAUÊ. Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03).

P.R.I.C. Mogi Mirim, 04 de novembro de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA